

1503020-51.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... em definitivo, pela prática do crime de tráfico de drogas - fls. 73/74), bem como aquela descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, tendo em conta a data dos fatos (05.02.2022), e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de modo que reconheço ter sido praticado o crime em reconhecido estado de calamidade pública, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503020-51.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503020-51.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON COSTA DE SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

CLEITON COSTA DE SANTANA foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea "j)", todos do Código Penal, porque, no dia 05 de fevereiro de 2022, por volta das 02h50min, durante o repouso noturno e em plena vigência de calamidade pública, decretada por ocasião da Pandemia do COVID-19, no interior de uma borracharia situada na Avenida Baronesa de Muritiba, nº 582, São Rafael, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, tentou subtrair para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho de telefone celular da marca Motorola, avaliado em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), dois relógios de pulso, avaliados cada um em R\$ 50,00 (cinquenta reais), bem como a quantia de R\$ 12,00 (doze reais), pertencentes a Zacarias Araújo da Silva, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o acionado foi citado, sendo apresentada resposta escrita à acusação.

Decisão saneadora proferida na sequência.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acusado.

Nos debates, as partes fizeram suas ponderações finais.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido procede.

Materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante, a fls. 01, do

Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, bem como do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega, acostado a fls. 14, além do Laudo Pericial do local dos fatos, a fls. 104/111.

Autoria emerge da prova, das circunstâncias e das declarações firmes e harmônicas das testemunhas e da vítima.

Interrogado na etapa policial, o acusado admitiu parcialmente os fatos, nos seguintes termos: "que na noite de ontem um conhecido que não quis dizer o nome lhe ofereceu a quantia de R\$1.000,00 (mil reais) para que lhe ajudasse a encher uma perua. Que foram até uma borracharia e este rapaz retirou algumas telhas e entrou no local, abrindo a porta por dentro para ele. Que o rapaz disse apenas para ficar lá e apertar um botão quando fosse determinado. Que estava no interior da borracharia quando foi surpreendido com a chegada do proprietário. Que não chegou a furtar nada e nega que estivesse na posse do aparelho celular e da quantia em dinheiro, mas confessa que estava com os dois relógios de pulso." (fls. 13).

Já em Juízo, confessou parcialmente os fatos, com novo colorido.

Doutro lado, a prova, de todo séria.

Chamada a prestar declarações em Juízo, a vítima Zacarias Araújo da Silva declarou que, na data dos fatos, por volta das duas horas da manhã, estava em casa quando recebeu uma ligação telefônica da central de monitoramento que possui no seu estabelecimento comercial. Informou a responsável que o alarme da borracharia havia disparado minutos antes e que, em visita ao local, perceberam que havia uma corrente quebrada na parte da frente. Diante destas informações, o declarante foi até o local. Chegando lá, a equipe de monitoramento também se encontrava presente. Assim que abriu o portão da borracharia se deparou com um indivíduo correndo em sua direção. Neste cenário, ordenou que o indivíduo parasse, tendo ele deitado no chão e soltado uma sacola que carregava, no interior da qual havia dois relógios, um aparelho celular e a quantia de R\$ 12,00 (doze reais), sendo todos estes pertences de sua propriedade. Acionou a Polícia Militar, que foi até o local e conduziu o suspeito até a Delegacia de Polícia.

Amparando as palavras da vítima, temos, então, as declarações firmes das testemunhas policiais ouvidas em Juízo.

Rafael Fernandes Maia e Augusto Gomes de Souza de Santana declararam, em versões absolutamente uníssonas, que, na data dos fatos, já no período da madrugada, foram acionados pelo COPOM para atender a uma ocorrência de furto a estabelecimento comercial. Diligenciaram ao local, onde foram recebidos pela vítima, proprietário do comércio, relatando que, momentos antes, havia sido acionado pela central de monitoramento em razão de haver sinais de invasão no local. Dirigindo-se até o estabelecimento, encontrou e deteve um indivíduo no seu interior, o qual estava na posse de alguns objetos de sua propriedade. Indagado, ainda no local, o detido confessou a prática delitativa, narrando que estava juntamente a um comparsa, o qual teria entrado no estabelecimento pelo telhado e, uma vez no seu interior, aberto a porta pelo lado de dentro, possibilitando a sua entrada. Este segundo indivíduo havia se evadido do local antes da chegada dos policiais militares.

Consigno que nada há nos autos a indicar que as testemunhas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Da mesma forma em relação à palavra da vítima, que também não conhecia o réu anteriormente e motivo algum possuía para maldizê-lo.

Assim, analisando a prova em seu conjunto, dúvida não me paira de que o ora acusado, no dia e horário descritos na Denúncia, vale destacar, durante período de repouso noturno, unido em comunhão de esforços e identidade de propósitos a indivíduo desconhecido, ingressou no estabelecimento comercial da vítima, mediante rompimento de obstáculo, consistente na entrada forçada pelo teto do local, cujas telhas foram removidas, e, já em seu interior, passou a se apoderar de bens materiais diversos que ali existiam, dentre os quais aqueles elencados no auto de exibição e apreensão de fls. 14, ou seja, um aparelho celular Motorola, dois

relógios de pulso e a quantia de R\$ 12,00 (doze reais em dinheiro).

Não obstante, em razão do acionamento da central de monitoramento que guarda o local, dirigiu-se a vítima até o seu comércio, logrando deter o criminoso ainda no interior, restando coartada sua ação delitiva, restrita, pois, à forma tentada. Vale asseverar que o encontro da res em poder do furtador gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuta a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório. (Apelação nº 519.559/7, Julgado em 09/05/1.988, 11ª Câmara, Relator: - Segurado Braz, RJDTACRIM 1/103).

Confira-se, ainda: A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu presunção de autoria de infração penal. (Apelação nº 569.933/2, Julgado em 01/03/1.990, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 6/132); Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. (Apelação nº 569.323/8, Julgado em 12/03/1.990, 10ª Câmara, Relator: - Sidnei Beneti, RJDTACRIM 6/134); Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. (Apelação nº 596.861/6, Julgado em 14/02/1.990, 9ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDTACRIM 6/140); Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente, autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se justificativa inequívoca, de modo que, a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório. (Apelação nº 792.381/8, Julgado em 31/05/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Roberto Mortari, RJDTACRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTACRIM 18/66); Em tema de delito patrimonial, a efetiva apreensão da "res furtiva" em poder do agente inverte o ônus da prova. (Apelação nº 863.933/4, Julgado em 28/06/1.994, 13ª Câmara, Relator: - Teixeira de Freitas, RJDTACRIM 22/126); A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria. (Apelação nº 932.599/2, Julgado em 10/04/1.995, 11ª Câmara, Relator: - Fernandes de Oliveira, RJDTACRIM 27/167); A apreensão da res subtraída em poder do acusado gera a presunção de autoria, invertendo o ônus da prova. (Apelação nº 1.046.821/3, Julgado em 03/04/1.997, 2ª Câmara, Relator: - Osni de Souza, RJDTACRIM 34/309).

Neste quadro, verifico que as provas são contundentes e militam em extremo desfavor do acusado, cuja versão fornecida não é capaz de elidir suas responsabilidades.

Assim, uma vez verificada a materialidade do crime de furto em comento, tenho para mim que a autoria também se confirmou.

Todavia, consoante a prova oral, o crime não chegou a se consumar, na medida em que os bens não chegaram a deixar o estabelecimento da vítima, motivo pelo qual de rigor o reconhecimento da forma tentada do delito, nos termos do art. 14, inciso II, do CP

É certo, ainda, que o crime se deu durante o período de repouso noturno, por volta das 02:00 horas da manhã, circunstância que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Desimportante, no caso, que o fato tenha ocorrido em estabelecimento comercial, notadamente porque a prática do delito durante a madrugada evidencia a maior vulnerabilidade do patrimônio.

Ainda, entendo devidamente comprovadas as qualificadoras decorrentes do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes.

Quanto à primeira, o Laudo Pericial de fls. 104/111 bem aponta que os criminosos destruíram parte do teto para viabilizar o ingresso no estabelecimento vítima, o que torna ausente de dúvidas a incidência da circunstância em comento.

Por sua vez, a comparsaria foi relatada pelo próprio acusado, que narrou ter agido em comunhão de esforços com sujeito desconhecido, visando ao fim criminoso comum da dupla.

Consigo, outrossim, não haver incompatibilidade entre o reconhecimento da forma qualificada do crime de furto e a incidência da causa de aumento decorrente da prática do fato durante o repouso noturno.

Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos."

E não é outro, diga-se, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do tema: "1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) - como se sabe o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática.".

Destarte, sem prejuízo da configuração do crime na forma qualificada (duplamente, inclusive), reconheço, também, a incidência da causa de aumento de pena decorrente do cometimento do delito durante o repouso noturno.

Desta forma, responde o acusado pela prática de um crime de furto, na forma tentada, majorado pela circunstância de tê-lo praticado no período de repouso noturno, e qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas.

Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira etapa da dosimetria, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis ao acionado, de forma que fixo suas reprimendas iniciais no mínimo legal.

Em segunda fase, se mostram presentes as circunstâncias agravantes da reincidência (autos nº 0029395-57.2018.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal Central, em que o réu foi condenado, em definitivo, pela prática do crime de tráfico de drogas - fls. 73/74), bem como aquela descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, tendo em conta a data dos fatos (05.02.2022), e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de modo que reconheço ter sido praticado o crime em reconhecido estado de calamidade pública, decorrente da notória pandemia do vírus COVID-19, circunstância de natureza objetiva.

Doutro lado, temos a confissão, que mesmo parcial, merece avaliação.

Assim, nos termos do art. 67, do Código Penal, exaspero as reprimendas anteriormente fixadas, unicamente, em patamar equivalente a 1/6, fixando o cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias multa.

Por fim, em terceira fase, incidem uma causa de aumento e outra de diminuição de penas.

De início, elevo suas reprimendas em 1/3, nos termos do art. 155, § 1º, do Código Penal, em razão do cometimento do crime em período de repouso noturno, conforme anteriormente fundamentado.

No entanto, em razão da modalidade tentada do delito, incide a causa de diminuição

prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, e, analisando o iter criminis percorrido pelo agente, que logrou acesso à parte interna do estabelecimento vítima, bem como a posse dos bens, sendo flagrado em estágio mediano da conduta, considero de rigor a redução de suas penas em somente 1/2. Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a sete dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo.

Fixo o regime semi-aberto para desconto inicial da pena corporal, tratando-se de acionado reincidente, não se mostrando suficiente e adequado, a reprimir o desvio de conduta, o estabelecimento do regime mais benéfico (aberto), tampouco as circunstâncias judiciais se mostrando manifestamente desfavoráveis a ponto de exigir o regime mais gravoso (fechado), na esteira do entendimento encerrado na súmula nº 269, do STJ.

Sobre o tema: Apelação nº 0002332-41.2009, rel. Desembargador ALEXANDRE ALMEIDA; Apelação nº 0001181-67.2009, rel. Desembargador AIRTON VIEIRA; Apelação nº 0011540-32.2009, rel. Desembargador OTAVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador ROBERTO SOLIMENE.

Por fim, ao cabo, e de saída, tratando-se de réu reincidente específico, não há espaço para conferimento de benefícios, em especial o sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal), e a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos (art. 44, do Código Penal).

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu CLEITON COSTA DE SANTANA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a sete dias multa, fixados no patamar unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado. Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados. Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2022.

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06